

教授と学生A及びBは次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑤までの()内に、後記アからケまでの【語句群】から適切な語句を入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。(改)

【会 話】

教 授: 犯人が被害者の住居に侵入した上で被害者を殺害した場合の住居侵入罪と殺人罪の罪数関係や、犯人が被害者の住居に侵入した上で被害者のお金を盗んだ場合の住居侵入罪と窃盗罪の罪数関係は、判例ではどうなるかな。

学生A: ①) です。

教 授: それでは、犯人が被害者の住居に侵入した上で、被害者を殺害し、その後に被害者のお金を盗もうと思いついて、現実にお金を盗んだ場合の住居侵入罪、殺人罪、窃盗罪の罪数関係は、判例ではどうなるかな。

学生B: 住居侵入罪と殺人罪が ①)、住居侵入罪と窃盗罪が ①) となり、全体として ②) になります。

教 授: そうだね。このような場合をかすかい現象と言っているんだ。

それでは、犯人が路上で被害者を殺害し、その後に被害者のお金を盗もうと思いついて、お金を盗んだ場合における殺人罪と窃盗罪の罪数関係は、判例ではどうなるかな。

学生A: ③) です。

教 授: 住居侵入罪の法定刑の上限は拘禁刑 3 年、窃盗罪の法定刑の上限は拘禁刑 10 年、殺人罪で有期拘禁刑を選択した場合の法定刑の上限は拘禁刑 20 年だけど、判例の立場によれば、前科のない犯人が被害者の住居に侵入した上で、被害者を殺害し、その後に被害者のお金を盗もうと思いついて、お金を盗んだ事案における処断刑の上限は、それぞれの罪について有期拘禁刑を選択した場合にはどうなるだろう。

学生B: ④) です。

教 授: それでは、判例の立場で、前科のない犯人が路上で被害者を殺害し、その後に被害者のお金を盗もうと思いついて、お金を盗んだ事案の処断刑の上限は、それぞれの罪について有期拘禁刑を選択した場合にはどうなるかな。

学生A: ⑤) です。

【語句群】

ア. 併合罪 イ. 牽連犯 ウ. 観念的競合 エ. 科刑上一罪

オ. 包括一罪 カ. 拘禁刑 20 年 キ. 拘禁刑 25 年 ク. 拘禁刑 30 年

ケ. 拘禁刑 40 年

1. ①イ ②エ ③ア ④カ ⑤ク
2. ①イ ②エ ③ア ④カ ⑤ケ
3. ①イ ②オ ③イ ④ケ ⑤カ
4. ①ウ ②エ ③ア ④ク ⑤キ
5. ①ウ ②オ ③イ ④ケ ⑤ク

No191	罪 数	正答率
H24-5	正 解	97%

①＝イ

牽連犯とは、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」（54条1項後段）をいう。いかなる場合に牽連犯となるかにつき、最大判昭24.12.21は、「数罪が牽連犯となるためには犯人が主観的にその一方を他方の手段又は結果の関係において実行したというだけではならず、その数罪間にその罪質上通例手段結果の関係が存在すべきものたることを必要とする」とする。住居侵入罪と窃盗罪は、その罪質上通例手段結果の関係が存在するので、牽連犯となる（大判明45.5.23）。また、住居侵入罪と殺人罪についても、その罪質上通例手段結果の関係が存在するので、牽連犯となる（大判明43.6.17）。したがって、①には「イ. 牽連犯」が入る。

②＝エ

最決昭29.5.27は、住居侵入罪と3個の殺人罪の関係について、「3個の殺人の所為は所論一個の住居侵入の所為とそれぞれ牽連犯の関係にあり刑法54条1項後段、10条を適用し一罪としてその最も重き罪の刑に従い処断すべき」として、科刑上一罪とする。学説は、住居侵入罪がかすがいとなり、全体が科刑上一罪となるとする（かすがい現象）。よって、②には「エ. 科刑上一罪」が入る。

③＝ア

裁判例（広島高判平20.4.22、東京高判平15.10.21）は、併合罪（45条前段）としている。したがって、③には「ア. 併合罪」が入る。なお、牽連犯となるかにつき検討すると、殺人罪と窃盗罪は、その罪質上通例手段結果の関係が存在しないので、牽連犯とはならない。又、観念的競合となるかにつき検討すると、観念的競合とは、「一個の行為が二個以上の罪名に触れ」る場合をいい（54条1項前段）、「一個の行為」とは、「法的評価をはなれ構成要件の観察を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上一個のものとの評価を受ける場合」をいう（最大判昭49.5.29、百選Ⅰ104事件）。犯人が路上で被害者を殺害し、その後に被害者のお金を盗もうと思ひ立ち、お金を盗む行為は、社会的見解上一個のものとは評価されないで、「一個の行為」とはいえず観念的競合とはならない。

④＝カ

住居侵入、殺人、窃盗の3罪は、②で述べた通り、全体が科刑上一罪となるため（最決昭29.5.27）、「最も重い罪により処断する」（54条1項）。本件で最も重い罪は殺人罪である（10条2項、130条、199条、235条）。そして、殺人罪について有期拘禁刑を選択した場合の上限は20年である（199条、12条1項）ので、本件の処断刑の上限は、20年となる。したがって、④には「カ. 拘禁刑20年」が入る。

⑤＝ク

殺人罪と窃盗罪は併合罪（45条前段）となる。そして、「併合罪のうちの2個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」（47条）。また、「有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ」る（14条2項前段）。本件で、最も重い罪は、殺人罪であり、有期拘禁刑の長期は20年であり（199条、12条1項）、その2分の1は10年であるため、処断刑の上限は、20年に10年を加えた30年となる。また、窃盗罪の法定刑の上限は拘禁刑10年であるから、処断刑の上限を30年としても47条ただし書には抵触しない。したがって、⑤には「ク. 拘禁刑30年」が入る。